

1500614-85.2021.8.26.0618
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Gustavo de Campos Machado
Comarca: Caçapava
Foro: Foro de Caçapava
Vara: Vara Criminal
Data de Disponibilização: 18/01/2022
... Fernandes).

No sentido de que a prática do tráfico com envolvimento de adolescente deve ser considerada como majorante prevista no art. 40, VI da Lei de Drogas, em prestígio ao princípio da especialidade, confira-se:

APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico ilícito de DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENORES -
Materialidade e autoria delitivas em relação ao tráfico sobejamente ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Caçapava
Foro de Caçapava
Vara Criminal
Rua Marquês do Herval, 269, Caçapava-SP - cep 12281-510
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500614-85.2021.8.26.0618 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500614-85.2021.8.26.0618
Classe - Assunto:
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante -
2111548/2021 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 17518717 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 908/21/323 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 908/2021 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 2111548 - Delegacia de Polícia de Caçapava
Autor:
Justiça Pública
Réu:
DAVID MAXIMILIANO DA SILVA
Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gustavo de Campos Machado

VISTOS.

DAVID MAXIMILIANO DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no Art. 33 "caput" da Lei 11.343/2006 e artigo 244-B "caput" do(a) ECA ambos c/c Art. 29 "caput" c/c Art. 69 "caput" ambos do Código Penal, porque, no dia 23 de abril de 2021, nesta cidade e Comarca, agindo em concurso de agentes e identidade de propósitos com o adolescente LUIZ GUSTAVO COLLI SOARES, para fins de tráfico,

trazia consigo e guardava drogas [conforme laudo de constatação provisória, fls. 38/43, e fotografias, fls. 30/35], sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Além disso, corrompeu o facilitou a corrupção de LUIZ GUSTAVO COLLI SOARES, menor de 18 anos de idade, ao praticar a infração penal com ele.

O réu foi notificado (fls. 135), apresentou defesa prévia (fls. 147), sendo recebida a denúncia em 27/08/2021 (fls. 156/158) e o acusado citado pessoalmente (fls. 194).

Durante a instrução, realizada virtualmente em razão da pandemia do novo coronavírus, foram ouvidas as testemunhas, bem como foi o réu interrogado. Em debates orais, o parquet pugnou pela condenação, enquanto a defesa requereu a absolvição.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A presente ação penal merece ser julgada parcialmente procedente.

A materialidade delitiva encontra-se provada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls. 1/4), Boletim de Ocorrência (fls. 5/9), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 28/29), Laudo de Constatação Provisória (fls. 38/43), Exame Químico-Toxicológico (fls. 126/129), Laudo de Exame em Celular (fls. 118/121) e pela prova oral coligida.

A autoria desponta nítida e indubitosa.

Em interrogatório judicial, DAVID MAXIMILIANO DA SILVA admitiu prática do tráfico, porém, negou conhecer o menor, esclarecendo que estava vendendo drogas para outra pessoa. Negou que estivesse vendendo drogas com o adolescente, esclarecendo que era vapor. Admitiu a propriedade apenas das drogas que foram apreendidas em seu poder, as quais pegou de um traficante apelidado de "Gordão". Desconhece o outro material apreendido na sua proximidade. Não sabe o motivo pelo qual os policiais disseram que admitiu contratar o menor Luiz Gustavo. Gordão não estava no local no momento de sua prisão. Estava vendendo drogas no local há uns quatro dias. Antes de começar a vender drogas, trabalhava com o genitor em um mercadinho da família, mas ele foi embora para Minas Gerais e acabou perdendo o emprego. Está arrependido de sua conduta.

Apesar do réu ter insinuado que não traficava em conluio com o menor LUIZ GUSTAVO, tal fato foi desmentido veementemente pelos policiais militares em juízo.

Com efeito, o policial militar THIAGO ROBERTO LONGHI, em juízo, asseverou que o comandante da cia de Caçapava deflagrou operação de combate ao tráfico de drogas no local dos fatos, conhecido como ponto de venda de entorpecentes, quando, durante incursão a pé no mato, visualizaram os dois indivíduos com sacolas nas mãos e mais outra pessoa, os quais saíram correndo para a região de mata ao visualizarem a polícia, mas foram detidos e abordados. O policial Leo deteve o adolescente e o declarante o acusado. Com David localizaram em sua sacola 28 eppendorfs de cocaína, 3 invólucros de maconha, 52 pedras de crack e R\$123,00 em dinheiro. Com o adolescente também encontraram drogas, a saber, maconha, cocaína e crack. O réu assumiu informalmente o tráfico, bem como de ter aliciado o adolescente a com ele traficar. Próximos aos agentes, localizaram um saco plástico de lixo com mais tijolos de maconha, pedra bruta de crack e quase 300 eppendorfs de cocaína semelhantes aos que eles estavam vendendo. David, de antemão, admitiu a propriedade das drogas e a prática do tráfico. Não conhecia o menor e o acusado anteriormente. O terceiro indivíduo foi conduzido, pois estava próximo ao réu e ao menor e se apresentou como usuário, fato confirmado pelos sindicados. Outro sujeito foi abordado na entrada do local com duas porções de maconha e confirmou ter comprado droga no local dos dois rapazes. Normalmente, quem delata traficante é "cagueta", mas, na ocasião, o terceiro indivíduo assumiu que havia acabado de comprar entorpecentes dos indivíduos. A pessoa cagueta costuma sofrer represálias do tráfico. Somente o réu e o adolescente estavam com sacolas nas mãos quando do ingresso no local.

A corroborar, o agente militar REGINALDO LEONARDO DOS SANTOS, em regular contraditório, confirmou que, na data dos fatos, durante operação no local dos fatos deflagrada por seu comandante, sua equipe ficou encarregada de entrar na mata pelos fundos. Nesse momento, viram David e Luiz com uma sacola nas mãos e outro

indivíduo, os quais saíram correndo. O declarante abordou o adolescente e o Sargento abordou David. Ambos estavam com drogas nas sacolas. Há uns trinta metros do local da abordagem, encontraram uma sacola plástica com dois tabletes de maconha, uma pedra grande de crack e quase 300 eppendorfs de cocaína semelhantes aos que estavam com o réu e o menor. David admitiu informalmente a prática do tráfico e disse que convidou o adolescente Luiz a traficar, fato confirmado pelo menor, segundo quem estava trabalhando para réu há três dias. O terceiro indivíduo estava no local apenas como usuário. Outro indivíduo foi abordado na posse de duas buchas e relatou que também comprou drogas de David e Luiz Gustavo. Não conhecia o réu e o menor.

Não há nenhum indício de insinceridade nas palavras dos policiais militares no sentido de que acusado e adolescente confessaram a prática em conluio do tráfico de drogas.

A esse respeito, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica quanto à validade dos testemunhos prestados por agentes policiais que tenham participado das diligências que culminaram com a captura do investigado ou com sua prisão em flagrante, tanto o mais quando não derruída a prova por outros elementos probatórios, como no caso em apreço.

Nesse sentido, "o valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com os outros elementos probatórios idôneos" (STF - HC nº 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.96, p. 39.846).

A testemunha comum CHARLES ASTORGA GONÇALVES, sob o crivo do contraditório, disse que havia acabado de chegar ao local no momento da prisão de David, pessoa que conhece de vista, assim como Luiz Gustavo. Disse que foi ao local para usar uma pedra de crack, momento em que saiu correndo com a chegada da polícia. Disse que prestou depoimento na delegacia em estado de choque, pois estava embriagado, não se recordando de ter dito que comprou droga de David e Gustavo. É usuário de entorpecentes há 18 anos e desde o ocorrido parou de usar drogas. Nunca comprou drogas naquele local anteriormente, ratificando que se deslocou para lá para usar drogas. David e Gustavo também foram abordados, mas não viu se a polícia achou drogas, pois estava drogado e em estado de choque. Não sabe quais são as consequências para aquele que é "cagueta" no tráfico. Quando saiu correndo, viu mais duas pessoas correndo, mas não sabe dizer quem são.

O dolo de traficar é manifesto e decorre da quantidade de drogas apreendidas, da diversidade das substâncias, do modo de embalagem, da presença de entorpecente a ser dividido em porções menores, das circunstâncias da diligência, precedida de denúncia anônima, ratificada pela apreensão de drogas no local e, por fim, da confissão informal dos envolvidos aos policiais.

Para Fernando de Almeida Pedroso, "em sede de tráfico de substância entorpecente, constituem prova indiciária do malsinado e vil comércio, exemplificativamente, a quantidade apreendida de estupefacientes, denotando sua incompatibilidade com a destinação para o próprio uso; a forma de fragmentação e acondicionamento do tóxico, confeccionado em diversas embalagens ou unidades distintas e individuais, indicando o propósito de venda a varejo" (cf. Prova Penal, 2ª ed., RT, 2004, item 5, pág. 96).

A propósito, sobre o tema, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo decidiu que "Para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida. O próprio artigo 37 da Lei Antitóxicos dá as coordenadas da caracterização do tráfico ao estipular que essa classificação se fará em consonância com a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminoso, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes do agente." (RT 584/347. Nesse mesmo sentido:

RT 714/357, RJTJSP 63/316, 70/371 e 97/512).

Nesse cenário, comprovadas a materialidade e autoria do delito, de rigor, pois, a condenação do acusado pelo crime de tráfico de entorpecentes.

Entrementes, tendo em conta que o delito de tráfico foi praticado pelo réu em concurso de agentes com o adolescente LUIZ GUSTAVO COLLI SOARES, incide, no particular, a majorante prevista no artigo 40, VI, da Lei nº 11.343/06, impondo-se a absolvição do acusado pelo crime de corrupção de menores previsto no artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Ao julgar fato análogo, o i. Desembargador LAERTE MARRONE, nos autos da Apelação Criminal nº 1500389-98.2018.8.26.054, julgada pela 14ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, bem pontuou que “a dicção legal, como anota GUILHERME DE SOUZA NUCCI, abarca duas situações: trazer o menor para o cenário das drogas, sob qualquer pretexto ou ter o menor como meta para o uso de drogas. Vale dizer, o menor como “participante ou vítima do tráfico de entorpecentes” (Leis penais e processuais penais comentadas, RT, 2ª edição, p. 344).

E conclui renomado Desembargador: “no caso de crime de tráfico de drogas praticado em concurso com criança e adolescente, tem-se um quadro de concurso aparente de normas, envolvendo a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, VI, da Lei nº 11.343/06 e o tipo penal de corrupção de menores, estampado no artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente. E, mercê do critério da especialidade, a hipótese enseja a condenação do agente pelo crime de tráfico de drogas, com a aludida majorante, afastando-se o delito de corrupção de menores, sob pena de “bis in idem”, entendimento que guarda apoio doutrinário (VICENTE GRECO FILHO, Tóxicos, prevenção-repressão, Saraiva, 13ª edição, pág. 211) e jurisprudencial (TJSP, Apelação nº 0011482-71.2010.8.26.0073, rel. Des. Pinheiro Franco; Apelação nº 0000615-55.2010.8.26.0352, rel. Des. Edson Brandão; Apelação nº 0019601-86.2010.8.26.0019, rel. Des. Silmar Fernandes).

No sentido de que a prática do tráfico com envolvimento de adolescente deve ser considerada como majorante prevista no art. 40, VI da Lei de Drogas, em prestígio ao princípio da especialidade, confira-se:

APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico ilícito de DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENORES –

Materialidade e autoria delitivas em relação ao tráfico sobejamente demonstradas

nos autos, tanto que sequer foram questionadas pela defesa ou pela acusação –

Condenação mantida – Recurso ministerial – Pretendida condenação pelo crime de

corrupção de menores – Desacolhimento – Prática do tráfico com envolvimento de

adolescente que deve ser considerada como majorante prevista no art. 40, VI da Lei

de Drogas, impedindo, destarte, dupla valoração da mesma conduta, sob pena de 'bis

in idem' – Precedentes – Absolvição mantida – Dosimetria – Aumento da pena-base –

Necessidade – Quantidade de entorpecente apreendido que autoriza a elevação da

sanção inicial – Inteligência do art. 42, da Lei nº 11.343/2006, que deve

preponderar sobre as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal

– Maus antecedentes que também devem repercutir negativamente na fixação da pena –

Afastamento da compensação da atenuante da confissão com a agravante da

reincidência – Acolhimento – Preponderância da agravante sobre a citada atenuante –

Dicção do art. 67, do CP – Regime fechado que se revelou o único cabível à espécie

– Hediondez e gravidade concreta do delito cometido pelo réu, somadas ao 'quantum'

da sanção imposta, aos maus antecedentes e à reincidência que determinam o

cumprimento da pena em regime mais gravoso, bem como desautorizam a concessão de

quaisquer benesses legais – Inteligência do art. 33, §3º, do CP – Recurso

parcialmente provido (TJ/SP; 4ª Câmara de Direito Criminal; Relator: Camilo Léllis;

j. 25/10/2021).

Passo, com fulcro nos artigos 42 da Lei n.º 11.343/2006 e artigos 59 e 68 do Código Penal, à dosimetria da pena.

Na primeira fase, diante da quantidade, variedade e natureza das drogas

apreendidas, notadamente do crack e cocaína, sabidamente de alto poder nocivo,

aumento a pena-base em 1/6, perfazendo o total provisório de 05 (cinco) anos e 10

(dez) meses de reclusão, além 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Anote-se que, consoante o disposto no artigo 42 da Lei n.º 11.343/06, na fixação da pena do crime de tráfico de drogas, o juiz deve considerar, com preponderância

sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente. Nesse sentido: STJ, HC n.º 402.845/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/09/2017, DJe 21/09/2017.

Na segunda fase de dosimetria, incidem as circunstâncias atenuantes da menoridade relativa e confissão. Presente, outrossim, a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea j do Código Penal, não se podendo negar que o acusado se valeu de uma situação pandêmica e dramática vivenciada pela coletividade, notoriamente reconhecida como calamidade, para o fim de obter renda fácil, passando a se dedicar ao tráfico, em prejuízo ao bem jurídico tutelado pela própria norma, qual seja, a saúde e bem estar da coletividade. Desse modo, realizo a compensação entre tais circunstâncias, mantendo as penas fixadas na fase anterior.

Na terceira etapa, presente a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, VI, da Lei nº 11.343/06, pois é inegável que o crime de tráfico de drogas foi praticado pelo réu em concurso o adolescente Luiz Gustavo, razão pela qual realizo o acréscimo de 1/6, o que enseja o total provisório de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, além de 680 dias-multa.

Todavia, o réu faz jus à diminuição de metade das penas com fulcro no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, o que resulta no total de 3 anos, 4 meses e 25 dias de reclusão, além de 340 dias-multa, pois, além de primário e sem antecedentes criminais (fls. 197/198), não há provas de que integre organização criminosa. No entanto, a apreensão em poder do réu de considerável e variada quantidade de drogas, em local conhecido como ponto de mercancia, na companhia de um adolescente, além de entorpecente a ser dividido em porções menores e dinheiro afastam a possibilidade da redução máxima da pena em virtude do privilégio, pois denota um envolvimento maior do réu com o crime, situação incompatível com a de um novato. Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, uma vez que não há nos autos elementos que comprovem a capacidade econômica do réu.

Excepcionalmente, fixo o regime aberto para o início do cumprimento da pena, tendo em vista o tempo de prisão preventiva (quase dez meses – artigo 387, §2º, CPP), as circunstâncias judiciais favoráveis ao acusado, sua primariedade, confissão e o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Não obstante este magistrado tenha reiteradamente decidido em casos idênticos de maneira diversa, ao adotar regime fechado no tráfico privilegiado, curvo-me ao recente posicionamento adotado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Habeas Corpus n.º 596.603 - SP (2020/0170612-1), de relatoria do MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ, adotando regime mais brando, em observância aos princípios da hierarquia jurisdicional e da segurança jurídica.

Em atenção ao balizado pela C. Superior Instância, reputo preenchidos os requisitos previstos pelo artigo 44, do Código Penal, razão pela qual substituo a pena privativa por duas penas restritivas de direito, quais sejam, a prestação de serviços à comunidade, que serão especificados pelo juízo da execução, e a prestação pecuniária, no valor de um salário-mínimo em favor de entidades assistenciais, recaiando, preferencialmente, em favor daquelas voltadas a reabilitação de dependentes químicos.

Ainda, quanto à possibilidade de substituição da pena corporal por restritiva de direitos, cabe observar o entendimento atual do Supremo Tribunal Federal: “A Turma concedeu parcialmente a ordem de habeas corpus para possibilitar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ao paciente condenado pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, desde que cumpridos os demais requisitos exigidos pela lei. Salientou-se que, uma vez verificada essa possibilidade, não há impedimento para que se fixe o regime inicialmente aberto para o cumprimento da pena, já que o objetivo da conversão é evitar o encarceramento. Frisou-se, ainda, que esse posicionamento busca apenas adequar a fixação do regime ao entendimento do STF, aplicando-se especificamente aos delitos de tráfico e apenas em razão da declaração de inconstitucionalidade das expressões da lei que vedavam a substituição. Precedentes citados do STF: HC 97.256-RS, DJe 15/12/2010; HC 104.423-AL, DJe 7/10/2010; HC 102.678-MG, DJe 23/4/2010, e HC 105.779-SP, DJe 21/2/2011”. HC 196.199-RS, Rel. Min. Gilson Dipp, julgado em

5/4/2011.

DISPOSITIVO

Posto isto e do mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal e, em consequência, CONDENO DAVID MAXIMILIANO DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 c.c artigo 40, VI, da Lei nº 11.343/06 ao cumprimento da pena de 3 anos, 4 meses e 25 dias de reclusão, em regime inicial aberto, além de 340 dias-multa, no menor valor unitário, ABSOLVENDO-O do crime previsto no artigo 244-B do ECA, na forma do artigo 386, III do Código de Processo Penal.

Substituo a pena privativa por duas penas restritivas de direito, quais sejam, a prestação de serviços à comunidade, que serão especificados pelo juízo da execução, e a prestação pecuniária, no valor de um salário-mínimo em favor de entidades assistenciais, recaindo, preferencialmente, em favor daquelas voltadas à reabilitação de dependentes químicos.

Tendo em vista o período em que o acusado se encontra preso preventivamente (quase 10 meses), o regime de pena aplicado (aberto) e a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, REVOGO a prisão preventiva, CONCEDEndo-LHE o direito de recorrer em liberdade. Expeça-se alvará de soltura clausulado, com urgência.

Autorizo a incineração das substâncias entorpecentes apreendidas, guardando-se pequena quantidade para eventual exame futuro, com a ressalva de que, com o advento da Lei nº 11.343/06, deverá ser observado o artigo 32, §2º, que exige a presença do Ministério Público, bem como de autoridade sanitária competente no local da incineração, elaborando-se, ainda, auto circunstanciado e perícia.

Declaro a perda do numerário apreendido em favor da União, nos termos da lei.

Com o trânsito em julgado: (i) expeça-se guia de execução; (ii) nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao IIRGD; (iii) oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; (iv) notifique(m)-se o(s) réu(s) para pagamento da pena de multa; (v) não sendo reclamados eventuais objetos apreendidos, estes serão destinados à leilão/doação, tal como previsto no artigo 123 do Código de Processo penal e artigo 517 das NSCGJ, independente de nova intimação; (vi) se o caso, expeça-se certidão de honorários em favor da patrona nomeada nos autos.

Publique-se, intime-se e cumpra-se.

Caçapava, 18 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA